

1502268-84.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF:

"A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502268-84.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502268-84.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2277312/2019 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 7573388 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES,

5044/19/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2277312 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES,

5044/19/306 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DE ARAUJO FERREIRA e outro

Juíza de Direito: Drª. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

EDUARDO DE ARAUJO FERREIRA e ERIK JOHNSON MESENCIO, qualificados nos autos, foram processados pela Justiça Pública e devidamente denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 333, caput, do Código Penal; e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de setembro de 2019, por volta das 08h40min, na Rua Projetada, altura do nº 79, Vila Nova Estação - Vila Paulista, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, traziam consigo, e mantinham em depósito, para fins de tráfico, cerca de: (i) 22,4g (vinte e dois gramas e quatro decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 03 (três) porções - papérolas -; (ii) 22,1g (vinte e dois gramas e um decigrama) da droga cocaína, acondicionada

em 03 (três) porções - papélotes -; (iii) 46,7g (quarenta e seis gramas e sete decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 26 (vinte e seis) porções - papélotes -; (iv) 24,5g (vinte e quatro gramas e cinco decigramas) da droga cocaína em forma de crack, acondicionada em 32 (trinta e dois) porções em invólucros plásticos; e (v) 65g (sessenta e cinco gramas) da droga Cannabis Sativa L, conhecida popularmente como maconha, acondicionada em 28 (vinte e oito) porções em invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, EDUARDO DE ARAUJO FERREIRA, qualificado nos autos, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para omitirem ato de ofício.

Houve prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva, conforme r. decisão proferida nos termos de audiência de custódia de fls. 69/71.

A denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2019 (fls. 206).

Os réus foram notificados (fls. 151 e 153), sem seguida, citados (fls. 223 e 231), e apresentaram resposta à acusação (fls. 181/182, 217 e 221).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 235).

Ao final, produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatórios dos réus.

O Ministério Público e a Defensoria Pública apresentaram alegações orais e a defesa do réu Eduardo apresentou memoriais (fls.306 e fls.311/315).

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade dos delitos está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 09/13, auto de exibição/apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 132/136, exame químico-toxicológico de fls. 137/140, e laudo do Instituto de Criminalística de fls. 197/200, bem como pela prova oral colhida.

Também, a autoria criminosa dos acusados evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Ao ser ouvida em Juízo, a testemunha Adalberto Oliveira Junior, policial militar, narrou que estava em patrulhamento preventivo pelo bairro, o qual visualizaram com dois indivíduos agachados. Ao perceberem que o local dos fatos é conhecido como ponto de vendas de substâncias entorpecentes, desconfiaram de os indivíduos estarem na prática de vendas. De forma silenciosa, se aproximaram deles. Constataram que os acusados, seguravam uma sacola, contendo drogas do tipo, crack, maconha e cocaína. Em seguida, realizaram a busca pessoal, e encontraram, com um dos indivíduos, três porções da droga cocaína, e dinheiro, já com o outro indivíduo, foi encontrado três porções da droga cocaína e um telefone celular. Os acusados alegaram ser usuários de drogas. Após serem presos em flagrante, afirmaram a traficância. Afirma que um dos indivíduos que estava segurando o dinheiro, ofereceu ao policial militar, para que fossem liberados, mas não se recorda, qual indivíduo que ofereceu. Diz que foi uma quantia no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em seguida, os levaram à Delegacia de Polícia. Esclarece que os dois indivíduos estavam manuseando/contando os entorpecentes. As embalagens apreendidas na busca pessoal, eram semelhantes as embalagens dos entorpecentes de dentro da sacola. Não os conhecia anteriormente.

No mesmo sentido, a testemunha Bruno Fernandes Galbiatti, policial militar, declarou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, quando adentrou com a viatura, depararam-se com dois indivíduos agachados com uma sacola, contando substâncias entorpecentes. Desembarcaram da viatura, foram em direção aos indivíduos, e iniciaram a abordagem. Havia certa quantidade de drogas com os dois acusados. Um dos indivíduos, havia drogas e um telefone celular, com o outro, havia drogas e dinheiro. Ao verificarem o conteúdo da sacola que estavam com os indivíduos, havia drogas do tipo, crack, cocaína e maconha. Depois da abordagem, os indivíduos afirmaram a traficância. Em seguida, foram levados à Delegacia de Polícia. Afirma que um dos indivíduos ofereceu cerca de R\$ 5.000,00, para não serem levados até a Delegacia. Não se recorda de qual indivíduo. As embalagens de drogas eram idênticas às embalagens da sacola. Não havia ninguém nas proximidades. Declara

que em todo o momento do ocorrido, os dois indivíduos estavam próximos. Não os conhece de fatos anteriores.

O acusado Eduardo de Araujo, em Juízo, disse que tem 22 anos de idade, possui dois filhos, trabalha atualmente, como ajudante de transbordo, já foi processado anteriormente. Esclarece que havia acordado cedo para comprar pão, e ao voltar, parou no local dos fatos, para comprar drogas, para uso próprio, depois iria trabalhar. Ao agachar para escolher a droga, o outro indivíduo também agachou, momento em que foram abordados pelos policiais militares. Alegando ser usuário. Não conhecia os policiais de fatos anteriores. Nega ter oferecido R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o policial não o prender. Disse que escolheu três drogas para consumo, e iria escolher outras, momento em que os policiais chegaram. Na época dos fatos, trabalhava, ganhava cerca de R\$ 300,00 (trezentos reais) por semana.

O réu Erik Johnson Mesencio, revel (fls. 287), não apresentou sua versão acerca dos fatos.

Com efeito, não obstante a negativa do acusado Eduardo, a autoria criminosa está suficiente demonstrada.

Os policiais militares, que não conheciam anteriormente os reus, apresentaram depoimento coeso e seguro.

Ressalta-se a palavra dos policiais, que de maneira segura, uniforme e convergente, descreveram com detalhes como ocorreu a ação policial, bem como a conduta dos acusados.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo" (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 28/4/2020).

Aliás, a Defesa não trouxe qualquer elemento de convicção capaz de realmente depreciar as provas acusatórias já mencionadas, eis que não evidenciada qualquer intenção de graciosamente prejudicar/incriminar no caso concreto (CPP, art. 156).

Ademais, o certo é que o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Dessa forma, o elemento subjetivo do tipo penal, restou plenamente configurado, tendo em vista, a ciência do réu em relação às drogas. Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF:

"A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

O delito de corrupção passiva praticado pelo réu Eduardo, em seu núcleo verbo do tipo oferecer, também ficou demonstrado pelo depoimento dos policiais.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade dos acusados quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo a dosar a pena.

Réu Eduardo de Araújo Ferreira

Delito de Tráfico de Entorpecentes

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade com fundamento no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mas em virtude da Súmula 231 do STJ, impossível sua incidência.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º

do artigo 33, da lei de Drogas.

É cediço que o tráfico, enquanto comércio ilícito altamente lucrativo, é atividade exercida segundo o domínio territorial. Através do uso ilegítimo da força, as organizações criminosas instituem formas de domínio sobre os pontos conhecidos de venda de drogas, falando-se, inclusive, em "propriedade", "arrendamento" e "locação" destes espaços.

Desta forma, o exercício da traficância, nestes locais, indica inserção do agente nesta estrutura e a sua dedicação às atividades criminosas, impossibilitando a incidência em seu favor da figura privilegiada. Além do que, a quantidade e diversidade de drogas e forma de acondicionamento é indicativa dessa dedicação às atividades criminosas.

No caso em tela, os agentes da lei foram contundentes em afirmar que os acusados foram presos em local conhecido como ponto de drogas. Ademais, a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, a quantidade de cocaína, distribuídas em 64 porções, além de maconha e a apreensão de dinheiro estrangeiro (5.000 sucos equatorianos), indicam que os acusados desenvolviam a mercancia com habitualidade.

Neste sentido:

(...) na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada (...) nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, (...) a apreensão (uma parte do entorpecente encontrada na posse do réu em local conhecido pela venda de drogas (...)) elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. AgRg no HC 568062/MS, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, quais sejam, 50 (cinquenta) eppendorfs de cocaína e 49 (quarenta e nove) invólucros de maconha, em local conhecido como "ponto" não poderia atuar se já não fosse dedicada ao crime, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que a paciente se dedicava às atividades criminosas, em consonância com o entendimento desta Corte. HC 541065/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda raposo, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020.

A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais". HC 474680/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019.

Encontrando-se devidamente fundamentado o reconhecimento da dedicação à atividade criminosa pelo Tribunal de origem diante da grande quantidade de droga e pela forma de armazenamento da droga, a desconstituição das premissas fáticas deduzidas no acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1293036/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018.

Consoante decidido pelas instâncias ordinárias, além da quantidade e da variedade de droga apreendida na posse dos agravantes - 75 (setenta e cinco) pedras de crack, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína e 29 (vinte e nove) de maconha -, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, embaladas e organizadas para a comercialização ilegal e entrega a consumo de terceiros, demonstram a dedicação para a prática da atividade ilícita. AgRg no HC 547549/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 29/05/2020.

Delito de Corrupção Passiva

Na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base, no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade com fundamento no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mas em virtude da Súmula 231 do STJ, impossível sua incidência.

Por fim, ausentes causas de aumento e/ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Ante o concurso material de delitos, a pena total será de 07 anos de reclusão e 510 dias-multa.

Réu Erik Johnson Mesencio - delito de tráfico de entorpecentes

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, que torno definitiva, eis que ausentes causas de agravantes e/ou atenuantes, causas de diminuição e/ou aumento de pena.

Para ambos acusados, O regime inicial será o fechado, conforme previsto no artigo 33, do Código Penal, em virtude da quantidade da pena aplicada, bem como para reprovação do delito praticado e prevenção, seja genérica ou específica. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus:

(i) EDUARDO DE ARAÚJO FERREIRA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no (i.i) artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, e (i.ii) o artigo 333, caput, do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, totalizando 07 anos de reclusão, em regime fechado, e 510 dias-multa, no mínimo legal.

(ii) ERIK JOHNSON MESENCIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade em 05 anos de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Solto por força da ordem de habeas corpus, o acusado Eduardo poderá recorrer em liberdade.

Entretanto, também beneficiado pela liberdade provisória, o réu Erick deixou de cumprir as medidas cautelares impostas, não compareceu aos atos processuais, tornando-se revel, em nítido descumprindo da ordem judicial.

Assim, diante do reconhecimento de sua culpabilidade, pelo decreto condenatório, e, frente ao descumprimento das obrigações legais impostas às fls.185/186, não poderá apelar em liberdade, devendo ser recolhido ao cárcere. Expeça-se mandado de prisão. Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 111).

Quanto ao valor de 5.000 sures equatorianos, oficie-se à autoridade policial para que informe se referida quantia foi depositada no Banco Central.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário

da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls.09/13).

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50, apenas para o acusado Erick Johson Mesencio.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA